

1504701-14.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... de liberdade por restritiva de direitos ao crime de tráfico de drogas, trago à colação o julgado do E. STJ:

" (...) 1. A nova Lei de Tráfico de Entorpecentes (11.343/06) dispõe que o delito de tráfico é insuscetível de sursis e, ainda, vedou expressamente a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504701-14.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504701-14.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2265315/2022 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 27719736 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2265315 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME FERNANDES NICOLAU DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos.

GUILHERME FERNANDES NICOLAU DOS SANTOS, qualificado a fls. 34, está sendo processado por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11. 343/2006 porque no dia 28 de setembro de 2022, por volta de 07h40., na Rua Thiago Azevedo dos Santos, altura do nº 19, no Jardim Frezzarin II, nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, trazia consigo 06 (seis) porções de crack, 07 (sete) porções de cocaína e 30 (trinta) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida por "maconha" (consoante auto de exibição a fls. 11/12 e auto de constatação preliminar de substância

entorpecente a fls. 16/18), tudo para fins de entrega a consumo de terceiros, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, o denunciado obteve, por meios ainda não esclarecidos, a posse das drogas descritas acima, para comercializá-la no endereço supramencionado.

Ocorreu que, na data dos fatos, guardas municipais estavam em patrulhamento pelo local quando visualizaram o indiciado que, ao notar a presença da viatura, jogou algo ao solo.

Diante da conduta suspeita do autuado, os guardas municipais deliberaram pela abordagem.

Realizada a revista pessoal, os guardas localizaram em poder do indiciado cinco pedras de crack, uma porção de cocaína, uma porção de "maconha" e a quantia de R\$110,00 em dinheiro. Em seguida, recuperaram o objeto arremessado anteriormente pelo indiciado e verificaram se tratar de mais vinte e nove porções de "maconha", uma pedra de crack e seis porções de cocaína.

Interrogado na Delegacia de Polícia, GUILHERME confessou o crime, afirmando que estava realizando a venda de drogas no local, que os entorpecentes apreendidos eram de sua propriedade e que o dinheiro apreendido era proveniente da venda de drogas (fls. 08).

Portanto, as circunstâncias da apreensão das drogas, a forma de acondicionamento, a quantidade, o encontro de dinheiro, aliada a confissão extrajudicial e ao relato dos agentes públicos, evidencia que as substâncias entorpecentes pertenciam ao denunciado e que se destinavam a entrega a consumo de terceiros.

O acusado foi notificado (fls.110). A denúncia foi recebida em 21 de novembro de 2021 (fls.111). Apresentou defesa preliminar (fls.87/89). O acusado foi citado (fls. 120). Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas em comum e o acusado interrogado ao final.

Em alegações finais, pugna o Ministério Público pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, face a comprovação da autoria e da materialidade delitivas. A defesa do acusado pugna pela absolvição por falta de provas ou, em caso de condenação, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação da pena base no mínimo legal e substituição por penas restritivas de direitos.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de fls. 09/10, auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação preliminar de fls. 16/18, laudo pericial de fls. 99/101 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa.

Os guarda municipal Rafael Crisp esclareceu que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, e avistou o acusado num ponto de tráfico de drogas. Ao avistar a viatura, ele correu e jogou algo ao solo. Foi abordado e no bolso da bermuda encontrou pequena quantidade de drogas, e R\$ 110,00. O envelope que ele soltou continha porções de maconha, crack e cocaína. Que indagado, admitiu que as drogas lhe pertenciam, estava fazendo a venda e que seu turno era das 07 da manhã até as

12 horas.

O acusado, em seu interrogatório, confessou os fatos. Disse que tinha acabado de pegar as drogas para vender. Que queria dinheiro para usar mais drogas, pois é usuário de entorpecente. Que devia R\$ 45,00 aos traficantes e foi para a biqueira vender drogas, pois daí pagaria sua dívida. É usuário de cocaína e maconha, tem 19 anos de idade, e estuda no segundo colegial. Já foi internado.

Pela prova oral colhida nos autos, em especial pela confissão do acusado, que não restou isolada, pois vai de encontro aos relatos firmes e sinceros dos guardas municipais, além do restante do conjunto probatório, formado pelas circunstâncias do local da abordagem, armazenamento da droga e da quantidade, entendo bem comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, impondo-se sua condenação.

Quanto ao valor probatório dos depoimentos de policiais, a jurisprudência é tranquila em reconhecer a validade e a importância de tais depoimentos, quanto mais se não existe nenhum elemento os autos para considerá-lo indigno, tal como se vislumbra dos julgados:

“PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente - A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra - Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição - Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido”. (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery - 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111).

“PROVA. Testemunha Policial. Validade. Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos. Recurso parcialmente provido”. (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9, Ibitinga, 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator: Alfredo Fanucchi 14.08.08 V.U. Voto n. 8007).

E neste caso, o relato dos guardas municipais encontra amparo no depoimento do acusado, que narrou com detalhes sua atuação delitiva.

Sendo assim, diante do conjunto probatório coerente e robusto, formado pelas circunstâncias de armazenamento da droga, da quantidade, ou seja, 06 porções de crack com 1,3g, 07 porções de cocaína com 1,4g e 30 porções de maconha com 60,2g, conforme laudo pericial (fls.99/101) entendo bem comprovada a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu. A condenação é medida que se impõe.

Passo, então, a dosar a pena.

Primeira fase. Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é primário e de bons antecedentes, mas o artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, e neste caso em concreto, ele comercializava elevadíssima quantidade de maconha, porções de cocaína e crack, conforme se observa do auto de exibição e apreensão de fls. 19/23 e fotografias de fls. 41/42. A natureza dos entorpecentes, cocaína e crack, também vêm em seu desfavor. O “crack”, principalmente, é substância esta que causa imediata

dependência e exerce um poder devastador sobre a saúde física e mental do usuário bem superior a outras drogas. Os prejuízos e as consequências nefastas desta droga são constatados diariamente, diante da ampla divulgação, pelos meios de comunicação, dos efeitos maléficos do crack, contribuindo efetivamente com o aumento da criminalidade e destruição de vidas e famílias. Por tais razões, quem comercializa este tipo de entorpecente, e nesta quantidade, merece uma reprimenda maior do Estado e deve ensejar a imposição de pena superior a que seria cabível se se tratasse aqui de tráfico de poucas quantidades de droga e de menor potencialidade lesiva. Por tais razões, merece uma reprimenda maior do Estado, conforme nos ensina Renato Brasileiro de Lima: "Como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele que é preso com um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela" (DE LIMA, Renato Brasileiro. Legislação criminal especial comentada, 2ªed., JusPODIVM, 2014, p. 787). Nesse mesmo sentido, têm decidido nossos Tribunais Superiores, fazendo alusão ao princípio da proporcionalidade: "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA. ENTORPECENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente lastreada na quantidade e natureza do entorpecente encontrado em poder do réu - pasta-base de cocaína, de alto poder deletério -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de fundamentação inidônea. 2. Agravo desprovido." (AgRg no RESp 1793804/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). Considerando, assim, tais circunstâncias - quantidade elevada e natureza do entorpecente - aumento a pena base de 1/3 (1/6 para cada circunstância desfavorável), totalizando 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal. Segunda fase: incide duas atenuantes: da confissão espontânea e da menoridade, voltando a pena ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Ausentes agravante. Terceira fase: ausentes causas de aumento e diminuição de pena, esclarecendo que não estão preenchidos todos os requisitos para a benesse legal. O acusado, apesar de ser primário e de bons antecedentes, já teve passagens na Vara da Infância e Juventude pela prática do mesmo delito (fls. 41), e meses antes deste fato fora preso em flagrante delito pela prática do mesmo crime, sendo agraciado com a liberdade provisória (fls. 39/40), e voltando a delinquir, demonstrou sua dedicação às atividades criminosas. Também tinha plena consciência de estar contribuindo para organização voltada para o tráfico de entorpecente, sobretudo diante da elevada quantidade de drogas apreendidas em seu poder. Ora, só quem goza de confiança dos demais membros da organização tem a tarefa de guardar tamanha quantidade de drogas em casa, até mesmo porque sabe-se do valor econômico deste material. Não seria destinada esta função para o iniciante, o desconhecido, aquele que não tem nenhum conhecimento da vida do tráfico, o que revela que ele estava integrado neste ambiente odioso. Comentando o § 4º do artigo 33, os autores Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na obra "Lei de Drogas Comentada", ed. Método, 1ª edição, p. 98, explicam que "o intuito da lei é somente beneficiar o 'pequeno traficante', que não possui conduta voltada para o crime e que não esteja envolvido 'definitivamente' com o tráfico".

O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o criminoso que comercializa grande quantidade de entorpecente não faz jus ao redutor legal, dada a evidência do seu envolvimento em atividades criminosas. Trago à colação: "HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06). PENA CONCRETIZADA: 7 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. APREENSÃO DE 157,3 KG DE MACONHA. PENA BASE DE 8 ANOS JUSTIFICADA. ELEVADA CULPABILIDADE PELA QUANTIDADE DE DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4o. DA LEI 11.343/06 EM RAZÃO DE AÇÕES PENAIIS E INQUÉRITOS EM ANDAMENTO. QUANTIDADE DE DROGA, TODAVIA, QUE INDICA A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARECER DO MPF

PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.1. É certo que todas as funções processuais penais são de inescondível relevância, mas a de denunciar, a de aceitar a denúncia, a de restringir prematuramente a liberdade da pessoa, a de julgar a lide penal e a de dosimetrar a sanção imposta exigem específico trabalho intelectual de esmerada elaboração, por não se tratar de atos burocráticos de simples ou fácil exercício, mas sim de atividade complexa, em razão de percutirem altos valores morais e culturais subjetivos a que o sistema de Direito confere incontornável proteção. 2. Na hipótese, a exacerbação da pena-base, ainda que se retire a menção aos maus antecedentes e, portanto, se reconheça a primariedade do paciente, não pode retroceder ao mínimo legal, uma vez que extremamente elevada a culpabilidade em razão da quantidade de droga apreendida.3. Inviável a aplicação do redutor do art. 33, § 4o. da Lei 11.343/06 no caso concreto, pois, apesar da primariedade do acusado, a expressiva quantidade da droga indica sua participação em organização criminosa. 4. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (STJ, HC 140.211/MS, 5ª turma, Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22.09.2009) (grifei).

Assim, afastada a incidência do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, as penas ficam fixadas em 05 anos de reclusão e 500 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, diante das circunstâncias concretas já apontadas, quantidade e variedade das drogas, além da natureza do crime que permanece assemelhado aos hediondos, nos ditames da Lei nº 8.072/90, redação dada pela Lei nº 11.464/07.

Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111.840/ES, em data anterior, ou seja, em 27/07/2012, por maioria de votos, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Ocorre que a decisão foi dada em controle incidental de constitucionalidade, o que significa dizer que valeu somente para aquele processo julgado; não tendo efeito erga omnes.

Não existe, assim, a obrigatoriedade da fixação do regime mais gravoso, como previa a lei, mas nada impede que no caso em concreto o Juízo entenda por aplicá-lo, por se tratar mais apropriado à espécie, sempre com vistas à efetiva prevenção e reparação do crime.

Não há como mitigar o juízo de reprovação incidente sobre a conduta delituosa em si mesma, que continua sendo a do tráfico ilícito de drogas. Trata-se de delito gravíssimo e que merece séria reprimenda, diante das consequências nefastas que causam à sociedade, seja com relação à saúde pública, onde se expõem pessoas inocentes a perderem sua integridade corporal diante do consumo de tóxicos, ou então em razão das demais consequências à sociedade em geral, tal como o financiamento do crime organizado ou a prática desenfreada de delitos contra o patrimônio para a aquisição de tóxicos.

Frente a este panorama, não se pode concluir que regime menos gravoso ou a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito sejam suficientes para o real alcance da pena, que deve servir de fator de retribuição ao agente, de readaptação social e prevenção de novas transgressões.

Pelas mesmas razões, ou seja, porque inadequado conceder-lhe tal benefício para efetiva prevenção e reparação do crime, deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.

A respeito do cabimento de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao crime de tráfico de drogas, trago à colação o julgado do E. STJ:

" (...) 1. A nova Lei de Tráfico de Entorpecentes (11.343/06) dispõe que o delito de tráfico é insuscetível de sursis e, ainda, vedou expressamente a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44). Portanto, cometido o crime na sua vigência, indevida a conversão da pena ou a concessão de sursis. 2. Recente entendimento do colendo STF afirma ser inconstitucional a proibição de conversão de penas em crime de tráfico (HC 97.256, Rel. Min. AYRES DE BRITO); todavia, deve ser ressaltado que foi (a) adotada em sede difusa; (b) por maioria de votos (6x4) e (c) sem efeito vinculante. 3. Não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou (...). (STJ, HC nº 203.403/ SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, d.j. 21/06/2011).

Nego o direito ao acusado de apelar em liberdade, pois presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP. A elevada quantidade de pena aplicada e o regime prisional mais gravoso exige o encarceramento para garantia da aplicação da lei penal. Não há nos autos prova de que o acusado exerça ocupação lícita, ao contrário, declarou estar desempregado e dedicado ao vício em entorpecente. Nada impede, assim, que fuja do distrito da culpa para furtar-se ao cumprimento desta pena. Também há necessidade de garantir a ordem pública. Solto, com sensação de impunidade e com esta conduta social reprovável, certamente voltará a delinquir. Necessário, assim, extirpar do seio da sociedade pessoas que conturbam a ordem pública. O Judiciário não pode se furtar à efetiva reprimenda do crime de tráfico de drogas, cujos efeitos são graves e nefastos, pois não só fomenta a prática de outros crimes, geralmente furtos e roubos por parte dos usuários, que tentam manter o vício, mas também porque seus agentes são verdadeiros causadores da destruição de vidas e famílias.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar GUILHERME FERNANDES NICOLAU DOS SANTOS, qualificado nos autos, às penas 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Expeça-se mandado de prisão, recomendando-se na que se encontra.

Condene o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido nos autos em favor da FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei de Tóxicos, pois não comprovada a origem lícita.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: a) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP; b) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; c) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu; d) proceda-se à incineração da droga apreendida, nos termos do parágrafo 1º do art. 32 Lei de Tóxicos; e) expeça-se guia de execução penal.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA